Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Nova Alvorada do Sul

Vara Única

Autos **0800652-16.2017.8.12.0054**
Autor(es): André Monteiro David
Réu(s) Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS

André Monteiro David ajuizou a presente ação com pedido de condenação dos requeridos **Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Nova Alvorada do Sul - MS** para que providenciassem todo o tratamento necessário, consistente implante intravitreo de Ozurdex, considerando ser portador de oclusão de veia central da retina com edema de polo posterior.

O NAT apresentou parecer desfavorável tendo em vista não ser indicado o procedimento pleiteado na inicial.

Concedida a tutela de urgência foi determinado o fornecimento do tratamento conforme pretendido na inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

Com efeito, pretende o autor que os requeridos forneçam o procedimento proposta na inicial, tendo em vista que não dispõe de condições financeiras para arcar com tal despesa e que ela não está sendo fornecida na rede pública.

De acordo com o art. 196, da Constituição Federal, *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 29/05/2019 às 18:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-16.2017.8.12.0054 e código pnluR8pg.

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No caso em tela, há prova suficiente da necessidade de realização do referida consulta, conforme indicação do médico (fls. 14/5 e 170). Tem-se também a negativa injustificada pelos requeridos (fls. 20).

A alegação de que a recomendação foi apresentada por medico não vinculado ao SUS encontra justificativa no fato de que o requerente aguardou por mais de um ano por uma consulta especializada, contudo não foi atendido na rede púbica.

Ademais, pelo que se tem dos documentos juntados na inicial, o paciente aguarda pelo procedimento há pelo menos dois anos, de modo que não há qualquer argumento que sirva como escusa para sua realização.

Por último, nem sequer a liminar foi cumprida, mesmo após a concessão do prazo de 30 dias, o que só colabora com a tese de omissão, motivos pelos quais o pedido merece procedência.

Multa cominatória

Primeiro, não prospera a alegação de inaplicabilidade da multa cominatória ou sua excessividade, pois pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor (*astreintes*), mesmo que seja contra a Fazenda Pública, seja porque não há essa limitação legal e, segundo, porque é meio apropriado apto a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação (art. 497, do Novo Código de Processo Civil), sobretudo em casos como esse.

Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que em caso semelhante decidiu o seguinte:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO-PROVIDO. Em situação de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 29/05/2019 às 18:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-16.2017.8.12.0054 e código pnluR8pg.

> inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro sobre o segundo, de sorte que, sendo urgente e impostergável a aquisição do medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do demandante, fica autorizada a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Tratando-se de obrigação de fazer é permitido ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública." (Rel.: Des. Josué de Oliveira; Comarca: Cassilândia; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data do julgamento: 06/05/2014; Data de registro: 07/05/2014) (sublinhei).

Liminar em face da Fazenda Pública

Do mesmo modo, não deve ser acolhida a alegação de não concessão de tutela em face da Fazenda Pública. Muito embora tenha-se reconhecido a constitucionalidade das restrições impostas pelo artigo 1º da Lei 9.494/1997 através da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 4, o próprio STF vem conferido interpretação restritiva ao referido dispositivo, diminuindo seu âmbito de abrangência, como é o caso relativo a direitos fundamentais que correm risco de lesão, em que se deve implementar um tratamento médico, sob pena de agravamento de uma doença.

Tal raciocínio foi adotado no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 798092/BA, de relatoria do insigne Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05 de março de 2014. Senão vejamos:

> "DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DA CADEIA PÚBLICA MUNICIPAL DA CIDADE DE GAVIÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POR VIOLAÇÃO ÀS LEIS 9.494/97 E 8.437/92. INOCORRÊNCIA. DEVER DO ESTADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PROTEÇÃO À VIDA E SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, I, DO CPC. CADEIA SEM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE FUNCIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VOGA.IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. 01. **Admissível a**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 29/05/2019 às 18:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-16.2017.8.12.0054 e código pnluR8pg.

> **concessão de antecipação dos efeitos da tutela em desfavor da Fazenda Pública, porquanto a situação em tela não se encontra inserida nas causas impeditivas insertas nas leis 9.494/97 e 8.347/92, uma vez que o interesse tutelado é bem jurídico à saúde, a defesa do direito fundamental à vida e a dignidade da pessoa humana, garantidos pela CF/88, não podendo, portanto, ser postergado** (...)." (STF - ARE 798092 BA – Min. Gilmar Mendes - 11/03/2014)

Portanto, apesar de sua abrangência, a lei 9.494/97 não engloba todas as hipóteses de antecipação de tutela em face do Estado, de modo que se a demanda não estiver no raio de incidência da citada norma, será possível a antecipação de tutela, desde que preenchidos os requisitos legais. Somando a isso, o poder constituinte atribuiu a todos os entes federativos o dever de propiciar os meios adequados à manutenção da saúde dos administrados e essa atribuição, por óbvio, abrange a obrigação de fornecimento de consultas e exames a pessoas que não tenham condições de adquiri-los, não podendo tais direitos serem limitados caso se mostre concretamente necessária sua análise em sede liminar, o que seria o mesmo que negar-lhe justiça em ofensa ao contido no art. 5º, XXXV, da CF.

Logo, deve ser conferida interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, a toda limitação abstrata à concessão de liminares contra a fazenda pública para que seja analisada caso a caso e, se mostrando suficientemente necessária essa, sob pena de perecimento do direito ou grave diminuição de sua eficácia, não há impedimento à apreciação.

Mesmo em caso de demandas de saúde deve ser analisada caso a caso a necessidade, não havendo, do mesmo modo, presunção inversa de urgência na análise.

Princípio da reserva do possível

Quanto à reserva do possível deve-se notar que é aplicação inadequada de teoria estrangeira (*Vorbehalt des Möglichen*), no caso 'numerus clausus' decidido pelo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 29/05/2019 às 18:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-16.2017.8.12.0054 e código pnluR8pg.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Nova Alvorada do Sul

Vara Única

TCF Alemão (*BVerfG*) sobre vagas no ensino superior, que em nenhum momento tratou de limitações orçamentárias.

Logo, não deve ser recebida a aplicada de forma simplista e equivocada tal teoria, não havendo ainda norma que autorize limitação de direito fundamental com base em alegação (nada mais que isso) de ausência de receita.

Posto isso, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e **acolho o pedido formulado na inicial**, confirmando a tutela antecipada, para o fim de determinar que os requeridos promovam o necessário para realização do procedimento de implante intravitreo de ozurdex no requerente, conforme prescrição médica, respeitando a tutela já concedida nos autos.

Para tanto, e evitando que haja preferência em desfavor de eventuais casos mais antigos, a parte requerida deverá demonstrar a ordem da fila para tanto e dar prognóstico razoável de tempo para atendimento.

Tal obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado.

Não apresentada a lista no prazo acima, presumir-se-a a omissão dolosa e que já ultrapassada a vez do requerente/substituído, acarretando obrigação de realização imediata do procedimento.

Sem custas, eis que os requeridos são isentos. Sem honorários, eis que o Ministério Público não os recebe (art. 44, I, da Lei 8.625/93).

Sentença sujeita ao **reexame necessário** (artigo 496 do NCPC).

Transitada em julgado **intimem-se** os requeridos, de imediato, para apresentarem, no prazo de 10 dias, relatório de regulação de vaga com a previsão de realização da cirurgia, caso ainda não tenha feito, sob pena de responsabilidade pessoal do faltoso e demais medidas indutivas e coercitivas, mormente porque a ordem vem sendo sistematicamente descumprida e isso não será admitido.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 29/05/2019 às 18:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-16.2017.8.12.0054 e código pnluR8pg.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Nova Alvorada do Sul

Vara Única

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Nova Alvorada do Sul, data da assinatura digital.

(assina por certificação digital)
Jessé Cruciol Junior
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JESSE CRUCIOL JUNIOR, liberado nos autos em 29/05/2019 às 18:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800652-16.2017.8.12.0054 e código pnluR8pg.